

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 甲は、酒に酔った状態で、自動車を無免許で運転した。甲には酒酔い運転の罪と無免許運転の罪が成立し、これらは観念的競合となる。
2. 甲及び乙は、対立する暴走族の構成員を襲撃することを共謀し、同構成員であるX、Y及びZに対し、殴る蹴るの暴行を加え、それぞれに傷害を負わせた。甲及び乙にはそれぞれ3個の傷害罪が成立し、これらは併合罪となる。
3. 甲は、乙がX及びYを殺害するつもりであることを知ったことから、凶器としてナイフ1本を乙に手渡したところ、乙は、同ナイフを用いてX及びYを殺害した。甲には2個の殺人幫助の罪が成立し、これらは併合罪となる。
4. 甲は、離婚した元妻Xを殺害する目的で、深夜、Xの母親Y宅に侵入し、その場にいたX、Y及びYの子Zを順次殺害した。甲には1個の住居侵入罪と3個の殺人罪が成立するが、住居侵入罪と各殺人罪は牽連犯となり、全体が科刑上一罪となる。
5. 甲は、身の代金を得る目的でXを拐取し、更にXを監禁し、その間にXの近親者に対して身の代金を要求した。甲には身の代金目的拐取罪、拐取者身の代金要求罪及び監禁罪が成立し、身の代金目的拐取罪と拐取者身の代金要求罪は牽連犯となり、これらの各罪と監禁罪は併合罪となる。

No195	罪 数	正答率
共通H27-17	正 解	88%
	3	

1 正しい

最大判昭 49.5.29 (百選 I 104 事件)。判例は、本記述と同様の事案において、無免許運転の罪と酒酔い運転の罪は、54 条 1 項前段の観念的競合の関係にあるとしている。その理由として、判例は、54 条 1 項前段にいう「1 個の行為とは、法的評価をはなれ構成要件の観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上 1 個のものとの評価をうける場合をいう」とした上で、「被告人が本件自動車を運転するに際し、無免許で、かつ、酒に酔った状態であつたことは、いずれも車両運転者の属性にすぎないから、被告人がこのように無免許で、かつ、酒に酔った状態で自動車を運転したことは、右の自然的観察のもとにおける社会的見解上明らかに 1 個の車両運転行為であつて、それが道路交通法……の各罪に同時に該当する」ということを挙げている。よって、本記述の甲には無免許運転の罪と酒酔い運転の罪が成立し、両罪は観念的競合となる。

2 正しい

最判昭 53.2.16。判例は、「数人共同して二人以上に対しそれぞれ暴行を加え、一部の者に傷害を負わせた場合には、傷害を受けた者の数だけの傷害罪と暴行を受けるにとどまつた者の数だけの暴力行為等処罰に関する法律 1 条の罪が成立し、以上は併合罪として処断すべきである」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、54 条 1 項前段の「1 個の行為」を、法的評価をはなれ構成要件の観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上 1 個のものとの評価を受ける場合をいうと解する立場 (最大判昭 49.5.29、百選 I 104 事件) から、最判昭 53.2.16 の上記事案は、自然的観察・社会的見解上、明らかに数個の行為があり、「1 個の行為」とは解されないことを挙げている。本記述においては、甲及び乙は、対立する暴走族の構成員を襲撃することを共謀し、同構成員である X、Y 及び Z に対し、殴る蹴るの暴行を加え、それぞれに傷害を負わせている。この場合、甲と乙の各暴行は、数個の行為であり、自然的観察・社会的見解上 1 個のものとの評価を受ける場合には当たらず、54 条 1 項前段の「1 個の行為」には該当しない。よって、甲及び乙には、X、Y 及び Z に対する関係でそれぞれ傷害罪が別個独立に成立し、これらは 45 条前段の「確定裁判を経ない 2 個以上の罪」に当たするため、併合罪となる。

3 誤っている

最決昭 57.2.17 (百選 I 107 事件)。判例は、本記述と類似の事案において、「成立すべき幫助罪の個数については、正犯の罪のそれに従つて決定されるものと解するのが相当である」としている。その理由として、判例は、「幫助罪は正犯の犯行を幫助することによって成立するものである」ということを挙げている。更に、同判例は、幫助罪が数個成立する場合に、観念的競合の関係となるか否かについては、「幫助行為それ自体についてこれをみるべきである」としている。その理由として、判例は、「幫助犯における行為は幫助犯のした幫助行為そのものにはかならない」ということを挙げている。本記述において、正犯である乙には X、Y それぞれに対する 2 つの殺人罪 (199 条) が成立するため、乙を幫助した甲には殺人幫助の罪が 2 罪成立することになる。そして、甲の幫助行為は、ナイフ 1 本を手渡したという 1 個の行為であるから、甲に成立する 2 つの殺人幫助の罪は、観念的競合の関係になる。

4 正しい

最決昭 29.5.27 (百選 I 106 事件)。判例は、本記述と同様の事案において、「3個の殺人の所為は所論1個の住居侵入の所為とそれぞれ牽連犯の關係にあり刑法 54 条 1 項後段、10 条を適用し一罪としてその最も重き罪の刑に従い処断すべきであ」としている。このように、本来併合罪の關係にある複数の罪が、各々と科刑上一罪の關係にある共通の他の罪を媒介として全体として一罪となつて考へ方を、「かすかい現象」という。かすかい現象を承認する判例の結論に賛成する学説は、その理由として、現行法の解釈論としてはかすかい現象を認めるほかないこと、刑法典の定める法定刑の幅が広いことからかすかい現象を肯定しても量刑上の不都合を回避し得ることを挙げている。よつて、本記述の場合、X、Y 及び Z 対する 3 個の殺人罪が成立し、それぞれ 1 個の住居侵入罪と牽連犯 (54 条 1 項後段) となり、全体として一罪となる。

5 正しい

最決昭 58.9.27。判例は、本記述と同様の事案において、「みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が、更に被拐取者を監禁し、その間にみのしろ金を要求した場合には、みのしろ金目的拐取罪とみのしろ金要求罪とは牽連犯の關係に」となつてゐる。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、54 条 1 項後段の「犯罪の手段若しくは結果である行為」を、犯人が主観的にその一方を他方の手段又は結果の關係において実行したというだけでは足りず、その数罪間にその罪質上通例手段結果の關係が存在すべきものであると解する立場から (最判昭 32.7.18)、身の代金目的拐取罪と拐取者身の代金要求罪は主観的にも客観的にも通常相互に手段・結果の關係にある類型に当たつてゐることを挙げている。更に、同判例は「以上の各罪と監禁罪とは併合罪の關係にある」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、身の代金目的拐取罪を継続犯と解すると、227 条 2 項を設ける必要はなかつたのであるから、本罪は状態犯と解すべきであり、継続犯である監禁罪とは罪質及び実行行為の類型を異にするので、監禁罪が吸収されるとは解されないこと、身の代金目的拐取罪の罪質を状態犯とみると、監禁罪と実行行為に重なり合いを認める余地がなく観念的競合 (54 条 1 項前段) ともみることができないこと、監禁に至らないまま殺害し、これと前後して身代金を要求するという事例や、誘拐後身代金要求と前後して被拐取者を遺棄するという事例もみられることから、身の代金目的拐取罪・拐取者身の代金要求罪と監禁罪との間に罪質上通常手段結果の關係にあると評価することはできず、牽連犯 (54 条 1 項後段) にもならないことを挙げている。